



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Emerson Mateus Borges, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta, no dia 27 de dezembro de 2016, na Al. Dino Bueno, por volta das 16h, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 800,5 gramas de maconha, e 13,3 de cocaína.

Determinada a notificação do réu (fls. 80), houve resposta (fls. 96/10) e a denúncia foi definitivamente recebida em audiência, quando foi colhida a prova oral e o réu interrogado, tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 117/118.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

A prova dos autos demonstra de forma cabal que o réu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

praticou os fatos imputados na denúncia, não merecendo acolhida quaisquer pretensões de desqualificar a palavra dos policiais.

De fato, os policiais ouvidos, contra quem não há nada de concreto nos autos, não havendo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão, foram uníssonos ao afirmar que suspeitaram do réu, resolvendo abordá-lo, sendo os entorpecentes encontrados na sacola que ele carregava.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os policiais para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão do réu (especialmente a enorme quantidade de maconha) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Ademais, embora o réu tenha admitido que estava carregando aquele entorpecente, sua versão de que não tinha certeza de seu conteúdo, e que tinha recebido apenas algumas drogas para levar aquela sacola, restou isolada de comprovação nos autos, sem nenhum elemento idôneo que a corrobore, carecendo, portanto, de qualquer credibilidade.

Fosse verdadeira sua versão, já de plano a teria informado aos policiais, inclusive prontificando-os a levá-los ao local onde iria entregar a droga, evidenciando assim sua suposta boa-fé.

Não foi, porém, o que ele fez, nada levando a crer que fosse realmente apenas uma “mula” sem saber o que havia na sacola. Note-se, especialmente, que se trata de região conhecida como cracolândia, onde há enorme tráfico, ficando evidente que a ação do réu era de abastecimento daquele local.

Assim, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base acima do piso legal.

O que indica a maior gravidade do delito, e recomenda uma exasperação da pena, é justamente a grande quantidade de maconha apreendida, sendo suficiente assim a centenas de porções, podendo atingir um enorme número de usuários. Não se pode, portanto, punir este delito da mesma forma que se tivesse sido apreendido com o réu apenas uma dúzia de porções, por exemplo.

Assim, no caso dos autos, aumento a pena base do réu em um ano acima do mínimo na fase do artigo 59 do Código Penal.

Não é reconhecida a atenuante da confissão, já que o réu alegou situação inverossímil e sem comprovação, visando mitigar sua responsabilidade, não podendo ser premiado com a redução da pena ao tentar enganar o juízo.

E, dada a enorme quantidade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciando sua ação de abastecer um dos locais de maior tráfico desta cidade, evidenciando não uma ação isolada e ocasional, mas sim a imersão no tráfico organizado, entendo descabido o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ausentes agravantes ou atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena, torno esta definitiva em 6 anos de reclusão, e 600 dias-multa, estes no piso.

Quanto às questões da liberdade provisória (o que alcança também o direito a recorrer solto), da possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade e do regime inicial da sanção, observo que o Supremo Tribunal Federal vem, ainda que de forma não unânime (havendo valiosíssimos votos divergentes), afastou a inflexibilidade das disposições legais expressas (vedação da liberdade e das penas restritivas, bem como regime inicial sempre fechado).

E as razões de tais entendimentos vêm bem esclarecidas na seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 279-333)

Ou seja, é evidente que um dos principais fundamentos do afastamento daquelas disposições legais inflexíveis foi a preservação do poder/dever de individualização das penas, nem de longe se podendo disso extrair que todo e qualquer tráfico de entorpecentes deva ser considerado como tendo a mesma gravidade e pelos mesmos critérios que qualquer outro delito, tais como um simples furto ou estelionato, por exemplo.

Ora, não se pode negar que tanto o Constituinte como o legislador ordinário sempre demonstraram que o tráfico de entorpecentes é um crime muito grave, e merece ser combatido com especial rigor. Vide nesse sentido não só os dispositivos atacados das Leis nº 11.343/06 e 8.072/90, como também os incisos XLIII e LI do artigo 5º da Constituição Federal.

Desta forma, tenho que a melhor interpretação das



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

decisões do Supremo Tribunal Federal, com o necessário e imprescindível respeito à vontade da sociedade expressada pelo legislador é a de que o sentido daquelas determinações específicas (maior rigor) deva ser a base de aplicação das penas para o crime de tráfico, mas com a flexibilidade de que, em situações diferenciadas de menor gravidade, se possa, em caráter excepcional, abrandar as sanções aplicáveis.

O tráfico de entorpecentes é uma atividade extremamente lucrativa, e a sanção para tal delito deve ser proporcional ao benefício que ele proporciona a quem o pratica, sob pena de prejudicar o objetivo da pena de dissuadir deste tipo de conduta.

Agir de outra forma, tratando o tráfico de drogas exatamente pelos mesmos critérios que qualquer outro delito não hediondo ou equiparado implicaria em transformar em letra morta as disposições, orientações e princípios contidos na Constituição Federal sobre tal delito.

Ora, no caso concreto, como já acima dito, as circunstâncias não indicam um crime de menor gravidade, praticado de forma absolutamente isolada e ocasional, mas sim a ação ligada ao tráfico organizado, abastecendo a cracolândia, potencialmente atingindo diversos usuários.

Por isso que, no caso específico dos autos, aplico o regime fechado como inicial, sendo negada a substituição da pena privativa de liberdade, tornando assim a sanção proporcional à gravidade do delito praticado, e em efetivo desestímulo a que não só o réu, mas mesmo outras pessoas, venham optar por este extremamente lucrativo e pernicioso delito.

E, pelas mesmas razões, tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, especialmente observando a pena aplicada e as circunstâncias desfavoráveis acima indicadas, não há razão para o reconhecimento de situação excepcional que justificasse o direito de apelar solto, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar **Emerson Mateus Borges**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

observada a progressão diferenciada, e 600 dias-multa, estes no mínimo legal.

O réu **não** poderá apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, **oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.**

Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, *a*, da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, **22 de fevereiro de 2017.**

Juiz de Direito: Dr. **Carlos Eduardo Lora Franco**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ciente:

Ministério Público:

Réu(s):

Defensor(es):